

员,应当对公司信息披露的五性负责,除非其有充分证据表明其已经履行勤勉尽责义务。张某某的辩护人称系公司前台、法务等相应的工作人员脱岗以及公司管理混乱导致张某某没有披露重大诉讼,张某某属于过失而非故意。但是在案证据证实,民事案件中张某某亦是被告,或是公司进行了上诉,并非张某某对涉及的重大诉讼事项一无所知,相反,在案证据完全可以证明张某某明知两起诉讼的存在而故意未披露相关信息。另,履行信息披露义务是上市公司的法定责任,公司人员脱岗和公司管理混乱属于公司内部管理事项,不影响本罪的构成,且本案中张某某显然未尽勤勉履职尽责。

二、刑事追诉中某公司的“重大诉讼”的披露时间节点和重大性的界定

(一)上市公司关于“重大诉讼”的披露时间节点

从上文可知,除公司半年度报告、年度报告等定期报告外,修订前后的《中华人民共和国证券法》均规定上市公司发生的重大诉讼属于重大事件,投资者尚未得知时,上市公司应当立即将有关该重大事件的情况向国务院证券监督管理机构和证券交易所报送临时报告。换言之,上市公司对于重大诉讼事项应当“及时”披露,且可以“随时”以临时报告的形式披露。某公司从得知重大诉讼事项到最终披露诉讼期间,先后发布2018年年度报告和2019年半年度报告等定期报告,均未披露上述两起重大诉讼事项,显然是未按照规定依法披露重大诉讼,明显违法。

实践中,关于重大诉讼事项临时报告的具体时点还存在一定争议,如是诉讼事件立案时还是上市公司收到诉讼材料时还是判决宣告或生效时?笔者认为,应坚持第一时间、及时披露的原则。因为重大诉讼的存在对于上市公司经营而言存在一定影响,并且影响投资者的决策,如果上市公司延时披露重要信息,无法实现对相应法益的保护。

(二)刑事追诉中关于重大诉讼事项“重大性”的认定

结合《最高人民法院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》规定,应以诉讼标的额作为分子,以诉讼发生时最近一期的净资产作为分母,判断是否属于重大诉讼。本案中,2019年4月29日,某公

司披露2018年年度报告显示净资产2.25亿元，此时两起诉讼标的额2亿余元，已达最近一期披露的净资产的80%以上，但某公司仍未对两起诉讼进行披露，2019年下半年发布的2019年半年度报告也未披露，显然已达立案追诉标准。并且通常来讲，公司当下的资产情况只能依据当时公司的资产状况，而不应当事后另定。本案中，某公司2018年年度报告经过会计师事务所审计，经查，该事务所还是“北京法院对外委托专业机构名册”中的司法鉴定机构。因此，无须另行委托第三方机构再次审计，2018年年度报告中确定的净资产可以作为判断诉讼重大性的定案依据。

编写人：北京市第三中级人民法院 顾珊珊 袁晓北

对非法经营同类营业罪“经营”行为的认定①

—— 陈某非法经营同类营业案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

重庆市第五中级人民法院(2023)渝05刑终233号刑事裁定书

2. 案由：非法经营同类营业罪

【基本案情】

一、非法经营同类营业罪

陈某利用担任市粮油总公司总经理、区粮食公司总经理的职务便利，与敖某、王某以粮油公司的名义合伙经营麦麸、有机小麦，三人商定共同出资、经

①入库案例，参见人民法院案例库2024-18-1-404-003。

营、管理，共担风险，利润平分。2009年至2012年，在陈某的安排下，粮油公司与市粮油总公司平均分配了向某公司供应麦麸的总量。2014年至2020年，陈某将市粮油总公司有机小麦的资质转让给粮油公司，并负责协调向某公司供应有机小麦的资质、指标，为粮油公司提供经营保障，安排区粮食公司收购粮油公司被拒收的有机小麦。陈某个人获取非法利益437.3626万元。

二、贪污罪

2015年8月至2020年6月，陈某利用职务便利，多次伙同郭某、姜某等人以虚增采购粮食单价的方式从区粮食公司套取资金174.79512万元，陈某分得44.45万元。

三、受贿罪

1. 2014年7月，钟某请托陈某、郭某利用区粮食公司资金、仓储等条件帮其解决向某公司供应有机小麦资金不足等问题，并通过协议方式承诺事成后送二人“好处费”的比例。2017年至2019年，钟某通过朋友蔡某获得向某公司供应有机小麦的指标后，陈某、郭某利用在区粮食公司任职的便利，提供区粮食公司的资金和场地给钟某使用，安排区粮食公司通过代收、代储、代交等方式帮钟某完成向某公司供应有机小麦的业务，钟某获利690.691398万元，钟某送给陈某、郭某346.1528万元，陈某分得173.0764万元。

2. 2011年至2022年，被告人陈某利用职务便利，为罗某、梅某、周某、李某、陈某、张某、敖某、左某等人牟取利益，单独或伙同他人收受前述粮食经销商、供应商给予的好处共

126 中国法院2025年度案例·刑事案例二

计130万元及价值1441.6元的财物，个人实得90 万元和价值1441.6元的财物。

【案件焦点】

行为人陈某利用职务便利为钟某经营的同类业务提供帮助并收受钟某钱款的行为是否属于经营行为，是构成受贿罪还是非法经营同类营业罪。

【法院裁判要旨】

重庆市綦江区人民法院经审理认为：被告人陈某在担任市粮食总公司、区

粮食公司总经理期间，利用经营管理方面的职务便利，与敖某、王某以粮油公司的名义合伙经营与其所任职的国有企业同类的营业，获取非法利益437.3626万元，数额特别巨大，其行为已构成非法经营同类营业罪；陈某以非法占有为目的，伙同他人套取公司资金174.79512万元，个人分得44.45万元，数额巨大，其行为已构成贪污罪；陈某利用职务便利为他人谋取经济利益，单独或伙同郭某多次收受“好处费”476.1528万元，个人实得263.0764万元及价值1441.6元的财物，数额特别巨大，其行为已构成受贿罪。判决如下：

一、被告人陈某犯受贿罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金50万元；犯贪污罪，判处有期徒刑四年，并处罚金25万元；犯非法经营同类营业罪，判处有期徒刑二年，并处罚金20万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑十二年，并处罚金95万元；

二、扣押在案的非法经营同类营业罪和受贿罪的违法所得及赃款共计700.58316万元依法予以追缴，上缴国库；对陈某贪污所得赃款44.45万元，依法发还被害单位。

一审宣判后，陈某提起上诉，认为其与钟某、蔡某系合作关系，收受钟某钱款不应定性为受贿罪。

重庆市第五中级人民法院经审理认为：虽然郭某与代表陈某和王某一起在利用利达公司向某公司供应小麦的业务中为该项目的完成实施了一些联系某公司以及联系小麦生产基地等联络行为，是与钟某之间为促成该业务实现的合作，但合作并非经营，郭某等人的行为并不是策划、组织和管理行为，并非法律规定的经营行为。陈某接受钟某等人的请托，利用其职务便利为钟某等人提供便利，并收受钟某等人给予的“好处费”，符合受贿罪的构成要件，应当以受贿罪认定。故，原判认定事实和适用法律正确，量刑适当。裁定：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

《中华人民共和国刑法修正案(十二)》对非法经营同类营业罪进行了修改：一是将犯罪主体由“董事、经理”扩大至“董事、监事、高级管理人员”，

与修订后的公司法衔接；二是扩大适用范围至民营企业在内的一般企业，旨在回应对民营企业保护的现实需要。当犯罪主体是国有公司、企业的董事、监事、高级管理人员时，利用职务便利为他人经营的同类营业提供帮助并收受财物构成非法经营同类营业罪还是受贿罪，是司法实践中的难点问题，应围绕是否有经营行为进行区分。

第一，是否有经营行为是非法经营同类营业罪与受贿罪在客观方面上的最大区别。两罪在犯罪行为的表象上存在相似之处，但在犯罪构成上仍有严格区别。非法经营同类营业罪的客观行为判断主要看行为人是否经营了同类营业，是否获取了数额巨大的非法利益。受贿罪客观行为是国家工作人员利用职务上的便利，索取他人财物，或者非法收受他人财物，为他人谋取利益的行为。因此，两罪的实质区别主要是客观上是否有经营同类营业的行为。非法经营同类营业罪必须要有经营行为，而受贿罪则是索取或收受他人财物的行为。与经营行为对应，非法经营同类营业罪中的非法利益带有经营利润性质，行为人非法经营同类营业的收入中部分为自己的经营收入。受贿罪中的非法利益是对行为人职务上作为或不作为的“酬谢”，行为人事事实上并未为他人提供经营活动，没有付出劳务，或者付出的劳务与其所得极不对等，其所获得的所谓“报酬”“辛苦费”等只不过是為了掩盖受贿犯罪而使用的各种名目。

第二，经营行为的具体认定应结合行为人是否参与策划、组织、管理等进行综合判断。经济活动中的经营，是指企业在物质生产和商品交换的经济活动中，搞好市场调查与预测，选定产品发展方向，制定长期发展规划，进行科学决策，达到预定的经营目标的过程。就非法经营同类营业罪的经营方式而言，既可以是为自己经营，又可以是为他人经营，还可以是既为自己经营又为他人经营；就其内涵而言，包含筹划、谋划、计划、规划、组织、治理、管理等含义。判断行为人是否参与经营同类营业，一是看实际策划、管理、决策。无论是自己经营还是为他人经营，非法经营同类营业罪通常要求行为人参与策划、管理、决策，仅投资而没有参与策划、管理、决策，不能认定为经营行为。特定情况除外，如行为人利用职务便利为特定关系人投资入股的公司、

二、破坏社会主义市场经济秩序罪 129

企业经营活动提供帮助，即使没有参与该公司、企业的管理和决策，也可以认定为该行为人自己经营。二是看盈利和亏损的分配、负担。经营的目的在于避免风险和盈利，参与经营的各方一般会对盈利分配和风险负担作出约定，如果参与的经营无风险或无须负担风险，则很有可能是以经营的形式掩盖不法利益输送。

结合本案，首先，陈某未参与钟某、蔡某经营的事前谋划。蔡某与钟某向某公司供应有机小麦的经营指标系蔡某凭借个人关系取得，陈某并未参与其中，只是蔡某、钟某在缺乏资金、仓储能力的情况下，才请托陈某、郭某帮助。

其次，陈某在钟某、蔡某的经营中无管理行为。在经营中，蔡某负责销售计划订单，钟某负责有机小麦基地相关工作的协调，陈某、郭某帮助解决资金、代收、代储、代交有机小麦的工作，而这恰是陈某在区粮食公司主抓的经营管理工作，可以看出陈某并未实际参与具体管理，只是利用职务便利为钟某、蔡某在资金、代收、代储、代交等业务上提供帮助，从而完成利益的交换。

最后，陈某在与钟某、蔡某的合作中不承担风险。在利润分配环节，陈某和郭某分走了利润的绝大部分，但从未与钟某约定如果亏损将如何负担的问题，明显不符合正常经营惯例。

综上，陈某将任职企业的资金、仓库提供给钟某使用，安排任职公司为钟某代收、代储、代交粮食的行为，既然不是策划、组织和管理行为，也就不属于经营行为，其收取钟某给予的好处并非基于经营，该行为不符合非法经营同类营业罪的构成要件，但符合受贿罪的犯罪构成要件，故应以受贿罪论处。

编写人：重庆市綦江区人民法院 徐贤飞
李红梅

为亲友非法牟利罪的认定

—— 刘某某为亲友非法牟利案

【案件基本信息】

1. 判决书字号

黑龙江省高级人民法院(2021)黑刑终83号刑事裁定书

2. 案由：为亲友非法牟利罪

【基本案情】

被告人刘某某，原某国有公司某分公司副总经理(副厅级)，2010年1月，被告人刘某某为解决其子刘某甲就业，安排成立某汽车租赁公司，刘某某与朋友、表弟等出资入股该公司，其中刘某某实际占股约43%，是公司最大股东，刘某甲主要负责该公司财务工作。2012年2月，为拓展业务，刘某某安排某汽车租赁公司出资成立某科贸公司，上述两家公司均由刘某某实际控制，且工作人员相同。2012年年底，刘某某利用担任某国有公司某分公司副总经理的职务便利，推荐其下属公司福州分公司向某科贸公司采购大米，福州分公司以210万元的价格向某科贸公司采购48650公斤五常大米，经鉴定，所采购的大米2013年1月在福州市的市场价格为87.57万元，某科贸公司非法获利122.43万元。该款项后被用于公司购车及日常经营等。

刘某某于2017年7月7日被指定居所监视居住，同年7月17日被刑事拘留，同年8月2日被逮捕。

【案件焦点】

1. 刘某某利用担任某国有公司某分公司副总经理的职务便利，让其下属公司福州分公司以高于市场价向某科贸公司采购48650公斤大米的行为如何定性；
2. 刘某某的犯罪金额如何认定。

【法院裁判要旨】

黑龙江省佳木斯市中级人民法院经审理认为：被告人刘某某身为国家工作人员，利用职务便利，非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额巨大，其行为已构成受贿罪；被告人刘某某身为国有公司工作人员，利用职务便利，以明显高于市场的价格向自己亲友经营管理的单位采购商品，而使国家利益遭受重大损失，其行为构成为亲友非法牟利罪。被告人刘某某犯数罪，应数罪并罚。被告人刘某某受贿犯罪所得893585.20元，为亲友非法牟利犯罪所得1224300元，合计2117885.2元应予没收，上缴国库。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款，第三百八十六条，第三百八十三条第一款第(二)项、第二款，第一百六十六条，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十九条之规定，认定被告人刘某某犯受贿罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币200000元，犯为亲友非法牟利罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币20000元，数罪并罚，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币220000元；扣押在案的被告人刘某某受贿、为亲友非法牟利犯罪所得予以没收，由扣押机关上缴国库，不足部分继续追缴，上缴国库。

刘某某提出上诉。黑龙江省高级人民法院经审理，裁定：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

本案最大的争议焦点在于如何认定为亲友非法牟利罪。为亲友非法牟利罪主要有以下特征：

第一，国有控股公司中从事公务的人员属于国有公司工作人员。国有控股公司中从事公务的人员属于国有公司工作人员。虽然刑法上的国有公司、企业是指国有独资公司、企业，但“国有公司、企业人员”并非仅指国有独资公

司、企业工作人员。经国有公司、企业提名、推荐、任命、批准等，在国有控股、参股公司及其分支机构中从事公务的人员，以及经国家出资企业中负有管理、监督国有资产职责的组织批准或者研究决定，代表其在国有控股、参股公司及其分支机构中从事组织领导、监督、经营、管理工作的人员，一般认定为以国家工作人员论的“国有公司、企业人员”。

第二，通过下属单位负责人的职权，安排以明显高于市场的价格购买商品，属于利用职务上的便利。利用职务上有隶属关系的其他国有公司、企业工作人员的职务便利可以认定其利用了职务便利。《全国法院审理经济犯罪案件工作座谈会纪要》第三条第一项规定，《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款规定的“利用职务上的便利”，既包括利用本人职务上主管、负责、承办某项公共事务的职权，也包括利用职务上有隶属、制约关系的其他国家工作人员的职权。担任单位领导职务的国家工作人员通过不属自己主管的下级部门的国家工作人员的职务为他人谋取利益的，应当认定为“利用职务上的便利”为他人谋取利益。

具体到本案，刘某某利用担任中国移动福建有限公司副总经理的职务便利，让其下属公司福州分公司以高于市场价向某科贸公司采购48650公斤大米，经佳木斯市发展和改革委员会价格认定五常大米2013年1月在福州市的市场价格为人民币875700元。某科贸公司非法牟利1224300元。因此刘某某的行为应当认定为“利用职务上的便利”为他人谋取利益。

第三，当行为人的行为兼具为自己以及亲友牟利的因素时，以为亲友非法牟利罪定罪更为合理。在具体案件中，应当考虑以下因素：行为人是否具有为亲友非法牟利的意图；行为人的行为是否不同于典型的贪污行为；以为亲友非法牟利罪进行处罚是否具有合理性。

综上所述，在认定为亲友非法牟利罪时，要求主体必须是国有公司、企业、事业单位的工作人员，客观方面表现为利用职务便利，为自己的亲友非法提供便利，致使国家利益遭受重大损害。通过下属单位负责人的职权，安排以明显高于市场的价格购买商品，属于利用职务上的便利，应当认定为亲友非法牟利罪。

编写人：黑龙江省高级人民法院 陈春鑫

(四) 破坏金融管理秩序罪

32

本金尚未归还的，应将集资参与者收到的红包、返利、消费补贴等回报，从本金中予以扣减后认定经济损失，同时向恶意第三方追缴违法所得退赔给各集资参与者

—— 某养老公司、东某非法吸收公众存款案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

广西壮族自治区北海市海城区人民法院(2022)桂0502刑初175号刑事判决书

2. 案由：非法吸收公众存款罪

【基本案情】

2016年6月5日，被告单位某养老公司与某房地产公司签订《商品房买卖合同》，约定由某养老公司以总价款1.23亿元向某房地产公司购买该房地产公司开发的某商业广场3号楼，开发成养老公寓。2016年年始，未经金融主管部门批准，某养老公司通过在北海市区派发宣传单等途径向社会公开宣传，向民众承诺在交纳养老服务费后，可获得养老床位的优惠及每年有8%至12%的消费补贴返还，如签订的合同到期后，不愿意续签的，可以退还之前缴纳的养老

服务费。2016年3月至2019年7月，某养老公司未经有关部门依法批准，以收取养老服务费为名向社会不特定对象299户（涉及351人）吸收资金共计2493.01万元，后通过对公账户以购房款的名义将上述款项交付给某房地产公司。截至2020年3月5日案发，某养老公司通过发放红包、消费补贴等方式给各集资参与人返利共计234.8845万元，给各集资参与人造成直接经济损失共计2258.1255万元。

2016年3月至2017年5月，被告人东某负责某养老公司的经营管理，具体负责某养老公司的事务，期间某养老公司向社会不特定对象吸收资金（收取养老服务费）共计572.11万元。2020年1月16日，东某向上海警方自动投案并如实供述其非法吸收资金的犯罪事实。

另查明，被告人东某因伙同东某华设立某养老服务公司非法募集资金，2022年3月11日上海市长宁区人民法院作出（2021）沪0105刑初1275号刑事判决书，以非法吸收公众存款罪判处被告人东某有期徒刑四年，并处罚金30万元。该判决已经生效。

再查明，2017年6月17日，广西壮族自治区北海市中级人民法院受理对某房地产公司的破产清算申请。同年9月12日，广西壮族自治区北海市中级人民法院裁定对某房地产公司进行重整。2018年7月17日，北海市中级人民法院裁定批准某房地产公司重整计划，终止某房地产公司重整程序。2020年11月3日，北海市中级人民法院裁定终止某房地产公司重整计划的执行，宣告某房地产公司破产。

【案件焦点】

1. 如何认定本案犯罪金额；2. 如何认定本案经济损失，向集资参与者支付的红包、返利、消费补贴、分红等，是否应从本金中予以扣减；3. 如何追赃挽损。

【法院裁判要旨】

广西壮族自治区北海市海城区人民法院经审理认为：被告单位某养老公司违反国家金融管理法律规定，非法变相吸收公众存款共计2493.01万元，数额

巨大，扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪。被告人东某自2016年3月至2017年5月担任被告单位的法定代表人，是直接负责的主管人员，参与被告单位非法吸收公众存款572.11万元的犯罪事实，数额巨大，扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪。东某在上海因犯非法吸收公众存款罪被判处有期徒刑四年，并处罚金三十万元，在判决宣告以后刑罚执行完毕以前，发现其在判决宣告以前还有非法吸收公众存款罪没有判决，应当数罪并罚。某养老公司、东某给集资参与人造成巨额经济损失，社会危害后果严重，均应依法予以严惩。对于某养老公司的犯罪所得共计2493.01万元，扣除集资参与人已领取的红包、消费补贴等共计234.8845万元，依法应追缴某养老公司转入某房地产公司的非法吸收的资金共计2258.1255万元退赔给各集资参与人。东某受其父亲东某华的指使、安排而参与被告单位的经营管理，其作用相对小，且有自首情节，依法可在量刑时予以减轻处罚。

综上，广西壮族自治区北海市海城区人民法院根据被告单位某养老公司、被告人东某犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照2015年修正的《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，第十二条，第六十七条第一款，第六十九条，第七十条，第四十五条，第四十七条，第五十二条，第五十三条，第六十四条；《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款，第三条第二款、第三款；《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条，第三条及参照《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条，第三条，第五条第一款、第二款第一项之规定，并经本院审判委员会讨论决定，判决如下：

一、被告单位某养老公司犯非法吸收公众存款罪，并处罚金100万元；

二、被告人东某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，并处罚金10万元；与前罪犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金30万元；数罪并罚，总和刑期有期徒刑六年，并处罚金40万元；决定执行有期徒刑五年，并处罚金40万元；

三、追缴被告单位某养老公司转入某房地产公司的非法吸收的资金共计2258.1255万元退赔给各集资参与人。

案件宣判后，判决已生效。

【法官后语】

本案是以签订“养老服务合同”为名侵害老年人合法权益的典型非法集资类案件。该类案件往往涉集资参与人数众多，且涉案钱款大多是老年人的“养老钱”，备受社会关注。本案的争议焦点在于如何认定犯罪金额，认定经济损失金额时，向集资参与人支付的红包、返利、消费补贴、分红等，是否应从本金中予以扣减以及如何追赃挽损等。

一、关于本案非法吸收资金的犯罪数额问题

《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条第三款规定，非法吸收或者变相吸收公众存款的数额，以行为人所吸收的资金全额计算，案发前后已归还的数额，可以作为量刑情节酌情考虑。相关报案陈述、报案书、自述材料、养老服务合同、收据、银行流水等证据足以证实某养老公司非法吸收公众存款的资金全额计算为2493.01万元。对于既无报案陈述或报案书，亦无相关养老服务合同、收据等证据予以佐证的6人，属证据不足，不予认定。

东某于2016年3月10日经登记为某养老公司的管理人员，同年4月29日经变更登记为法定代表人、股东，其中法定代表人任职时间至2018年4月8日变更登记为曾某。涉案养老服务合同、会计凭证等证据证明在2016年3月至2017年5月在涉案养老服务合同上盖有东某的法定代表人印鉴共计156份（156户168人），涉案资金共计572.11万元。东某作为被告单位的法定代表人，是依法负有直接责任的主管人员，参与被告单位非法吸收公众存款572.11万元的犯罪事实，应对其担任该公司法定代表人期间该公司非法吸收资金572.11万元的行为承担主管人员的刑事责任。

二、关于本案的经济损失及赃款追缴问题

《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理非法集资刑事案件适

用法律若干问题的意见》第五条关于涉案财物的追缴和处置问题规定：“向社会公众非法吸收的资金属于违法所得。以吸收的资金向集资参与人支付的利息、分红等回报，以及向帮助吸收资金人员支付的代理费、返点费、佣金、提成等费用，应当依法追缴。集资参与人本金尚未归还的，所支付的回报可予折抵本金”。可见，对于被吸收的本金尚未归还的，集资参与人因资金被吸收所获取的利息、分红等回报可予以折抵本金。

本案中，某养老公司支付红包、消费补贴给集资参与人，集资参与人所领取的红包、消费返利、消费补贴等均系被告单位非法吸收资金后向各集资参与人支付的回报，应从本金中予以扣减后认定经济损失数额。根据在案的银行流水、集资参与人陈述、报案书、自述材料、电话询问记录、养老服务合同、收据、签字折扣单等证据，对照吸收资金的数额，某养老公司非法吸收公众存款金额共计2493.01万元，已通过返还红包、消费补贴等方式支付回报给各集资参与人共计234.8845万元，故各集资参与人的经济损失共计2258.1255万元。

认定经济损失后，追赃挽损工作成为处理该类案件的重中之重。被告公司及被告人名下财产不足以退赔集资参与人经济损失时，如何最大程度为集资参与人追赃挽损是各集资参与人最关心的问题。经梳理银行流水、网上转账受理单、对公客户回单、账户交易明细单回单及证人证言等证据，发现某养老公司向不特定对象吸收资金234.8845万元后，扣除已通过返还红包、消费补贴等方式支付给集资参与人的回报，余款2258.1255万元犯罪所得已由某养老公司以购房款的名义给付某房地产公司。而某房地产公司作为某养老公司成立时的发起股东之一，在2016年参与非法吸收公众存款，且该公司的法定代表人、股东某华同时又是某养老公司的实际控制人，故认定广西某房地产公司获取涉案2258.1255万元资金并非善意取得，广西某房地产公司明知某养老公司通过违法犯罪的手段向社会公众吸取资金仍然恶意收取并使用，依法应向广西某房地产公司追缴涉案2258.1255万元资金退赔给各集资参与人。该举措有效防止空判，破解追赃挽损困局，助力社会矛盾进一步化解。

编写人：广西壮族自治区北海市海城区人民法院 李新敏

不能仅靠被告人认罪认罚 就认定其具有自洗钱行为的主观故意 ——李某非法吸收公众存款案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

广东省潮州市中级人民法院(2022)粤51刑初13号刑事判决书

2. 案由：非法吸收公众存款罪

【基本案情】

2019年6月开始，被告人李某以其网店需要刷单为由，许诺高额利息及佣金，通过网络吸引吴某某等75人在其网络店铺进行虚假交易，后将钱款存放于其提供的微信、支付宝等账户，或以“转账单”“续单”等方式直接吸收吴某某等75人的存款。至2021年9月，被告人李某通过上述方式，先后吸收吴某某等75人资金共计人民币14345199元，其中付还本息共计6065400.19元，至案发还尚有被吸收的资金共计8279798.81元无法归还。

被告人李某于2021年9月25日到公安机关投案。

【案件焦点】

李某对公诉机关的指控认罪认罚，能否据此认定其具有自洗钱行为的主观故意。

【法院裁判要旨】

广东省潮州市中级人民法院经审理认为：被告人李某违反国家金融管理制

度，变相吸收公众存款，数额巨大，其行为扰乱了金融秩序，已构成非法吸收公众存款罪，应依法予以惩处。被告人李某犯罪以后自动投案，归案后能如实供述自己的罪行，是自首，且已偿还部分资金，依法予以从轻处罚；被告人李某认罪认罚，对其予以从宽处罚。据此，判决如下：

一、被告人李某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币500000元，限于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳；

二、责令被告人李某自本判决发生法律效力之日起十日内退赔违法所得人民币8279798.81元给75名集资参与人（详见附表）；

三、随案移送的电脑主机一台、手机三部予以没收，上缴国库。

一审宣判后，判决已生效。

【法官后语】

准确认定洗钱罪，要坚持主观因素与客观因素相统一的刑事责任评价原则，“为掩饰、隐瞒上游犯罪所得及其产生的收益的来源和性质”和“有下列行为之一”（提供资金账户的；将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；通过转账或者其他支付结算方式转移资金的；跨境转移资产的；以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的）都是构成洗钱罪的必要条件，主观上具有掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益来源和性质的故意，客观上实施了掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益的来源和性质的行为，同时符合主客观两个方面条件的，应当承担刑事责任，并与上游犯罪数罪并罚。认定上游犯罪和自洗钱犯罪，都应当符合各自独立的犯罪构成，上游犯罪行为人为完成上游犯罪并取得或控制犯罪所得后，进一步实施的掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益的来源和性质的行为，都属于自洗钱行为。本案的争议焦点是仅凭被告人认罪认罚能否认定被告人具有自洗钱行为的主观故意。

笔者认为，不能仅靠被告人李某认罪认罚及最后供述就认定其具有其主观上具有掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益来源和性质的故意，而应结合其供述变化和具体客观行为予以综合评判。理由如下：

1. 被告人李某在2022年10月9日之前的供述中提到转移120万元的目的

